

1500719-37.2021.8.26.0594
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Mario Ramos dos Santos
Comarca: Lençóis Paulista
Foro: Foro de Lençóis Paulista
Vara: 2ª Vara
Data de Disponibilização: 04/02/2022
... 7/287).

Especificamente no tocante ao tráfico de entorpecentes tem-se:
"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Materialidade e autoria devidamente
comprovados - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas e servem
para embasar decreto condenatório - Recurso não provido. Os funcionários da polícia
merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Lençóis Paulista
Foro de Lençóis Paulista
2ª Vara
Avenida Padre Salústio Rodrigues Machado, 599, Lençóis Paulista-SP - cep 18683-471
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500719-37.2021.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500719-37.2021.8.26.0594
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
CAIO GABRIEL SILVA

Réu Preso
Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mario Ramos dos Santos

Vistos.

CAIO GABRIEL SILVA, qualificado a fls. 05 e 27/28, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois alega-se que, no dia 27 de junho de 2021, às 21h45min, na esquina da Rua Uruguai com a Rua Amazonas, Jardim Alvorada, nesta cidade e Comarca de Lençóis Paulista, transportava, para venda, 4 tijolos de "Cannabis sativa", com peso líquido total de 2950g, substância entorpecente prevista na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, sem autorização e em desacordo com determinação legal e Regulamentar. Nos termos da denúncia, segundo se apurou, o denunciado conduzia o veículo Fiat/Punto Attractive, placas FNF6F22, pelo Bairro Elizabeth, quando passou por uma viatura da Polícia Militar, percebeu que seria abordado e empreendeu fuga, passando a ser perseguido. Os Policiais decidiram abordá-lo porque já tinham informações de que o proprietário do carro, Caio, vinha praticando tráfico de drogas. Na Rua Uruguai, Caio perdeu o controle da direção do carro, colidiu contra o imóvel de número 314 e deu sequência à fuga a pé, caindo ao

chão logo em seguida, sendo, então, detido pelo Policial Tales. Realizada vistoria no veículo, os Policiais encontraram quatro tijolos de "maconha". Indagado, Caio falou que tinha pouca droga no carro, depois disse que tinha ido buscar a "maconha" em Pederneiras, pagando R\$ 500,00 por cada tijolo, sem indicar o nome de quem comprou. Já na Delegacia, o denunciado afirmou, informalmente, à autoridade policial que buscou a droga na cidade de Pederneiras e que ganharia a quantia de R\$ 700,00 (fls. 09). Auto de exibição e apreensão da droga a fls. 12/13 e laudo de constatação provisório a fls. 14/19. Auto de apreensão e auto de vistoria do veículo, constatando os danos, a fls. 10/11 e 41 (fls. 100/102).

Vieram aos autos deste processo o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), os termos de depoimentos dos policiais (fls. 03/04), o termo de interrogatório do réu (fls. 05), o boletim de ocorrência nº 363/2021 (fls. 07/09), os autos de exibição e apreensão do veículo e do entorpecente (fls. 10/11 e 12/13), o laudo de constatação de entorpecente (fls. 14/19). O acusado passou por audiência de custódia e teve sua prisão convertida em preventiva (fls. 70/74). Vieram aos autos, ainda, o relatório final do inquérito policial (fls. 90/91) e o laudo definitivo de entorpecentes (fls. 336/339). A denúncia foi oferecida (fls. 100/102). O denunciado foi notificado (fls. 184). O defensor do réu apresentou defesa prévia com pedido de liberdade provisória (fls. 186/191). Foram juntadas aos autos as certidões e F.A. do denunciado (fls. 168/170 e 178). Foi juntado aos autos pedido de restituição de coisa apreendida e documentos formulado por terceiro (fls. 108/114, 116/129 e 130/134), o qual o nobre representante do Ministério Público se manifestou contrário (fls. 181/182). O requerimento de restituição de coisa apreendida, bem como o requerimento de liberdade provisória foram indeferidos por este juízo e a denúncia recebida (fls. 201/205). Em audiência de instrução, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 23 de setembro de 2021, procedeu-se as oitivas das testemunhas comuns, quais sejam, PM Tales Pedro Fernandes Gouveia e Delegada de Polícia Márcia Regina dos Santos. Pela DD. Promotora de Justiça e pelo defensor do réu foi dito que insistiam na inquirição das seguintes testemunhas, PM Willys Fernando Cavalcanti da Silva, sendo por este Juízo homologado referida insistência. Em audiência de instrução em continuação, realizada excepcionalmente de forma virtual, no dia 16 de dezembro de 2021, procedeu-se a oitiva da testemunha comum, qual seja, PM Willys Fernando Cavalcanti da Silva e das testemunhas defesa, quais sejam, Lazaro Michel Afonso dos Santos e Joel Soares e, ao final, interrogado o réu, Caio Gabriel Silva.

Em alegações finais, a nobre representante do Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, nos termos da denúncia. Pugnou também pelo perdimento do veículo apreendido, vez que o veículo foi utilizado pelo réu para a prática de grave crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendido no dia da abordagem (fls. 344/364).

O ilustre defensor do réu, em alegações finais, pugnou, em caso de condenação, que sejam observadas as atenuantes de confissão espontânea (art. 65, III, d, CP); preponderância na fixação da pena (art. 42, da Lei de Drogas); causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixando no mínimo legal, convertendo-a em restritivas de direitos. Pugnou também que o denunciado possa apelar em liberdade nos termos do art. 283, CPP, por preencher os requisitos objetivos para tal objetivo e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou a fixação do regime inicial aberto (fls. 368/384).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ante a acurada análise do quadro probatório presente nos autos, tem-se que é PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, pois restou comprovada a materialidade e autoria do ilícito penal descrito no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, senão vejamos.

A materialidade do delito vem consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), nos termos de depoimentos dos Policiais Militares (fls. 03/04), no boletim de ocorrência de nº 363/2021 (fls. 07/09), no auto de exibição e apreensão de objeto (fls. 10/11), no auto de exibição e apreensão de entorpecente (fls. 12/13), no laudo de constatação de entorpecente nº 209145/2021 (fls. 14/19), no relatório final do inquérito policial (fls. 88/89), no laudo definitivo de entorpecentes nº 209151/2021 (fls. 336/339), bem como na prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Conforme auto de exibição e apreensão, foram apreendidos 04 tijolos de maconha, pesando 2.950 gramas (fls. 12).

Outrossim, segundo consta do laudo pericial de constatação de substância entorpecente nº 209145/2021 (fls. 14/19), as análises realizadas tiveram os seguintes resultados: DETECTADA presença de substância THC (Tetrahidrocannabinol), constante na lista F2 (lista das substâncias Psicotrópicas de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualização posteriores.

Além disso, segundo o laudo pericial de nº 209.151/2021 (fls. 336/339), as análises físicoquímicas realizadas nos materiais descritos no auto de exibição e apreensão revelaram os seguintes resultados: DETECTADA presença de substância THC (Tetrahidrocannabinol), constante na lista F2 (lista das substâncias Psicotrópicas de uso Proscrito no Brasil) da Portaria SVS/MS 344/98 e atualização posteriores.

Desta forma, não resta dúvida de que os entorpecentes encontrados por ocasião da diligência dos policiais, eram substâncias previstas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, as quais não tinham qualquer autorização e ainda se encontravam em desacordo com determinação legal e regulamentar, restando a materialidade devidamente configurada.

Quanto à autoria, o conjunto probatório leva à conclusão de que o denunciado foi responsável pela prática delitiva. Vejamos.

O denunciado Caio Gabriel Silva relatou, em juízo, "que é verdadeira a denúncia; que a mãe estava desesperada, tem irmão autista e estava sem dinheiro; que ficou desesperado; que é usuário de maconha e biqueira; que o interrogado se ofereceu para buscar a droga; que pegou o carro da mãe sem ela perceber; que era para encostar num veículo Astra prata, deu o dinheiro e pegou a droga; que na volta deu com os policiais, ficou nervoso, fugiu com o carro e bateu; que saiu correndo e fugiu com a droga; que estava escuro e sem óculos e caiu num buraco; que daí o policial chegou, pegou o interrogado e algemou; que o interrogado disse que a droga caiu no trio; que não acharam e foi inquirido de novo; que depois outro policial achou; que os policiais foram na casa, fizeram vistoria, nada acharam e foi levado para Bauru; que falou para a Delegada que recebeu R\$ 700,00 para buscar a droga; que não é bandido e nem criminoso; que esse carro é de Eduardo, amigo da mãe e tem garagem; que Eduardo emprestou o carro para a mãe levar o irmão no médico; que tem 23 anos, solteiro, bicos de servente; que já foi pego como usuário, pego com maconha; que não conhece as testemunhas e nada tem contra elas; que não precisou de atendimento médico na prisão. As vezes toma remédio para dormir; que quem pediu para buscar a droga foi o Magrão da Cruzeiro; que o carro estava emprestado para a mãe, mas não sabe se está financiado; que não andava com esse carro".

A confissão do réu de que efetivamente trazia consigo a droga é corroborada pela prova oral. Assim, por estar a confissão do denunciado harmonizada com os demais elementos probatórios, tem-se que a autoria do delito fixa-se na sua pessoa.

A testemunha Delegada de Polícia Marcia Regina dos Santos relatou, em juízo, "que é Delegada de Polícia há 14 anos; que apresentada a ocorrência pelos policiais,

conversou com caio; que o réu disse que buscou a droga em Pederneiras, mas não falou de quem; que só falou que ia ganhar dinheiro para trazer; que, quando do interrogatório, o réu não quis se manifestar; que, então, a depoente disse que seria testemunha da confissão informal do réu; que, se não se confunde, parece que o carro era do pai ou algo parecido; que os Policiais Militares falaram que já havia denuncia contra o réu no sentido de que o acusado traficava na casa ou perto da casa; que não recorda se os policiais foram ou não na casa do réu; que Caio disse que receberia R\$ 700,00 para buscar a droga; que não verificou o carro e não se recorda de alteração do original do carro".

A testemunha Policial Militar Tales Pedro Fernandes Gouveia relatou, em juízo, "que é Policial Militar há 08 anos; que atendeu a ocorrência; que estava em patrulhamento e daí viram um veículo Punto em alta velocidade e resolveram abordar; que dado sinal, o veículo não obedeceu, seguiu em marcha até colidir em um muro de uma residência; que o condutor desembarcou e correu; que o depoente correu atrás do condutor Caio, já conhecido; que perseguiu o réu, que entrou na mata, que sofreram quedas, até que Caio caiu de uma altura de 02 a 03 metros; que daí abordou; que o PM Willys, no carro, localizou aproximadamente 3kg de maconha debaixo do banco; que viu o carro e só tinha insufilm. Não havia alteração do original para geral compartimentos de transporte de droga; que o réu Caio disse que fugiu porque tinha pequena porção de droga no carro; que depois de saber do encontro da droga, Caio disse que comprou em Pederneiras a droga por R\$ 500,00 o quilo; que tinha informação de que Caio fazia a distribuição da droga no Jardim Cruzeiro, na Praça em frente à escola Leonina; que as denúncias falavam que Caio tinha os veículos Punto e Gol G4; que foi a primeira vez que viu Caio com o Punto. Com o Gol já tinha abordado antes; que as denúncias começaram cerca de 01 mês ou 01 mês e meio antes, no sentido de que 05 pessoas cuidavam do tráfico na região: que 03 foram presos trazendo droga de Birigui, 01 era Caio e o outro está solto; que Caio falou que o veículo era da mãe dele. Inclusive a mãe dele compareceu ao local para ver o carro e falou que havia comprado esse veículo; que, além da droga, só havia uma carteira vazia; que após a mãe do réu comparecer ao local, o depoente explicou à mãe e ela autorizou olhar o quarto dele; que foram na casa, vistoriaram o quarto do réu e nada foi encontrado".

O Policial Militar Willys Fernando Cavalcanti da Silva relatou, em juízo, "que é Policial Militar há 12 anos; que na data dos fatos estava em patrulhamento, quando se deparou com um veículo Fiat Punto em alta velocidade; que passaram a acompanhar e o conduto fugiu e, então, chocou-se contra um muro e, ato contínuo, fugiu à pé, entrando num matagal; que o réu Caio foi encontrado num buraco de 05 metros de distância; que foi algemado; que no veículo havia 04 tijolos de maconha; que Caio disse que comprou cada tijolo por R\$ 500,00, em Pederneiras; que Caio foi levado à Delegacia de Bauru; que o condutor do veículo era o indivíduo encontrado no buraco; que o réu estava sozinho no carro; que a droga estava o assoalho debaixo do banco, normalmente; que só conhecia o réu de abordagens anteriores, sem crime; que quanto ao réu, já havia informação de que ele estava traficando no bairro; que antes dos fatos, fez apenas 01 ou 02 abordagens e foram recentes; que nessas abordagens nada foi encontrada; que só foi encontrada a droga no carro".

A testemunha de defesa Joel Soares relatou, em juízo, "que não presenciou a atuação da Policia e nem a prisão do réu; que conhecia Caio, porque o depoente da aula de capoeira e Caio era aluno; que quando Caio foi levado para o depoente, Caio estava tendo problemas com uso de drogas; que nunca ouviu comentários de que Caio vendesse drogas; que Caio, para o depoente, sempre foi boa pessoa, nem sabia do envolvimento com drogas; que Caio tem um irmão mais novo deficiente; que Caio trabalhava de servente de pedreiro; que faz cerca de 04 meses que o último treino; que não usa droga lá; que perto do depoente e na academia o réu não apresentava visual de uso de drogas; que o réu treinou por 02 anos, que Caio não era aluno frequente. Quando aparecia não notada uso de drogas".

A testemunha de defesa Lázaro Michel Afonso dos Santos relatou, em juízo, "que não presenciou a atuação da polícia e nem a prisão de Caio; que conhece o réu desde criança, porque Caio treinou capoeira com o depoente e fez serviço de pedreiro; que o último trabalho com Caio foi de pintura; que Caio fumava baseado; que Caio é um excelente menino, faz tudo o que é pedido; que Caio sempre foi correto no serviço; que as drogas não prejudicava Caio no serviço; que Caio pediu adiantamento de valores do serviço, mas o depoente não tinha. Que Caio pediu o dinheiro para ajudar o irmão menor".

A prova oral supra transcrita, aliada aos demais elementos probatórios presentes nos autos, sobretudo considerando a confissão do denunciado acerca do ilícito, são capazes de formar, com a certeza e segurança necessária e exigível, a convicção desse Julgador no sentido de que o acusado violou a norma incriminadora descrita no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Cabe salientar que, no caso dos autos, o fator "quantidade da droga" induz ao tráfico, sobretudo frente ao contexto fático em que se deu a apreensão em questão.

Os policiais militares, em patrulhamento de rotina, avistaram o veículo Punto, conduzido pelo réu, em alta velocidade, razão pela qual decidiram proceder a abordagem. Dado o sinal, o réu empreendeu fuga, vindo a se chocar contra o muro. Ato contínuo, continuou a fuga à pé, sendo alcançado e capturado pelos policiais. Em revista pessoal e no veículo, lograram êxito em encontrar 4 tijolos de entorpecentes no interior do veículo.

Ressalta-se, inclusive, que é praxe comum entre aqueles que se dedicam à espúria mercancia empreenderem fuga quando avistados por policiais militares.

Obtempera-se que os depoimentos prestados em juízo pelos policiais que participaram das diligências são harmônicos, uníssonos, coerentes e guardam total consonância com as informações e com as demais provas.

Assim, tendo os policiais atuado dentro da legalidade e manifestado precisamente aquilo que presenciaram, não há que se falar em suspeição pelo simples exercício da atividade, até porque ter-se-ia absoluto absurdo no fato do Estado contratar agentes para o exercício de tão relevante função e, após, quando tais agentes fossem prestar contas de seu trabalho, o mesmo Estado negasse eficácia às suas declarações.

Assim tem entendido a jurisprudência:

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Sinésio de Aquino - RJTJRJ 7/287).

Especificamente no tocante ao tráfico de entorpecentes tem-se:

"TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Materialidade e autoria devidamente comprovados - Depoimentos policiais que corroboram com as demais provas e servem para embasar decreto condenatório - Recurso não provido. Os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador." (Apelação Criminal n. 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.)" (destacamos).

Ou ainda:

"TÓXICO - Tráfico - Condenação baseada em depoimentos policiais - Depoimento seguro

e coerente ao incriminar o acusado - Palavra destes, que somada as demais provas, merece total credibilidade - Presença, ademais, de testemunhas civis - Condenação mantida - Recurso não provido. O depoimento exclusivo de policiais é de toda validade quando coerente e corroborado pelas demais provas coligidas nos autos." (Apelação Criminal n. 181.618-3 - Tietê - 4ª Câmara Criminal - Relator: Augusto Marin - 12.06.95 - V.U.).

Considerando a harmonia e homogeneidade dos detalhes, circunstâncias e demais elementos probatórios, tem-se que é imperiosa a conclusão de que o réu efetivamente transportava elevadíssima quantidade de entorpecente, o qual destinava-se ao espúrio comércio. Logo, a condenação pelo crime de tráfico descrito na exordial é de rigor.

A combativa defesa sustentou, em resumo, que o réu é usuário de entorpecente desde o início de 2014, quando respondeu por ato infracional e que recentemente passou a consumir cocaína; que Caio estava trabalhando, mas percebendo que sua mãe estava sem dinheiro para comprar remédio para o seu irmão, portador de necessidades especiais, e não logrando êxito em emprestar o dinheiro do seu empregador, aceitou a empreitada de transportar a droga de Pederneiras para Lençóis Paulista/SP, recebendo o importe de R\$ 700,00, ou seja, transporte ocasional; que o réu é primário, possui residência fixa, junto com a sua mãe, e exerce a profissão de servente de pedreiro, além de destacar a inexistência de maus antecedentes.

Obtempera-se que a primariedade do acusado, bem como os elementos elencados pela defesa não têm o condão de afetar a conduta típica e antijurídica praticada.

Considerando que a defesa não trouxe qualquer outro elemento de cognição apto para alterar ou acrescentar ao robusto quadro probatório supra transcrito, constata-se que a mesma não se desincumbiu do ônus probatório ao qual estava adstrita.

Nesse diapasão, há elementos probatórios mais que suficientes para a formação da convicção deste Juízo no sentido de que o entorpecente encontrado destinava-se à mercancia espúria, o que implica violação à norma presente no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Contudo, desde já, diante das circunstâncias do fato, bem como da ausência de condenação anterior, reconheço a incidência no presente caso da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Tóxicos, pois, embora o denunciado tenha passagem quando era menor, fato é que o réu não possui condenações anteriores, não podendo ser afastado tal privilégio. Assim, é tecnicamente primário e, embora haja demonstração de que o réu é traficante, não há prova efetiva de que o réu integre organização criminosa ou que vinha se dedicando reiteradamente ao tráfico de entorpecentes.

Logo, preenchidos os pertinentes requisitos legais, a aplicação da referida causa de diminuição é imperiosa. Assim tem entendido a jurisprudência:

"Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa". (STJ - HC - 489.043 - SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJU: 12/03/2019).

Isto posto, passo à fixação da pena.

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, e no art. 42 da Lei de Drogas, considerando as circunstâncias e consequências do delito, sobretudo a quantidade e natureza da droga apreendida (2.950g de maconha), fixo a pena-base acima do mínimo legal, qual seja, OITO ANOS DE RECLUSÃO. Obtempera-se que a fixação acima do mínimo legal decorre sobretudo da elevadíssima quantidade de drogas transportada

pelo réu para fins de tráfico, demonstrando periculosidade do agente, elevado grau de lesão à ordem pública (potencialidade de atingir elevado número de usuários). Aliás, assim tem entendido a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO DE 4 ANOS PELA GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. DESPROPORCIONALIDADE PATENTE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo. 2. O aumento da pena-base quanto ao delito de tráfico em 4 anos, em razão da grande quantidade do entorpecente, não revela desproporcionalidade patente a ser revista em recurso especial, em se considerando, sobretudo, as penas mínima e máxima cominadas e o disposto no art. 42 da Lei 11.343/06. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1757348 AL 2020/0236270-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2021).

Em prosseguimento, não se vislumbra a existência de circunstâncias agravantes e atenuantes. Ao contrário do alegado pela defesa, não há que se falar na atenuante de confissão do réu, pois, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, irrelevante, para o deslinde de ação penal, a confissão do denunciado.

Ora, segundo a jurisprudência, a incidência dessa atenuante na segunda fase da dosimetria da pena somente é aplicável quando ainda é desconhecida a identidade do autor do fato, pois tal atenuante tem como objetivo a busca pela verdade real. Isso não se verifica “in casu”, dado que o agente foi surpreendido em posse dos entorpecentes. Logo, a confissão do réu foi irrelevante para a descoberta do crime, destacando-se que o denunciado sequer confessou de quem havia comprado, etc.

Nesse sentido:

“A confissão espontânea apta a beneficiar o acusado, a que alude o art. 65, III, 'd', do CP, é aquela feita quando ainda desconhecida completamente a identidade do autor do fato, ou quando apontado outrem. Tal não ocorre quando as diligências já se desencadearam rumo ao agente, que então confessa. Apelação improvida” (TARS - AC - Rel. Luiz Gonzaga Pila Hoffmeister - RT 619/360).

Não há causas de aumento de pena.

Assim, em face da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tal reprimenda é reduzida em dois terços, perfazendo o total final de DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO.

Nesse sentido, tal redução em dois terços justifica-se, pois, o acusado é primário e não há notícias nos autos da filiação do réu à organização criminosa ou que se dedique às atividades criminosas.

Obtempera-se, por oportuno, que o réu deverá iniciar o cumprimento na pena privativa de liberdade no regime FECHADO, “ex vi” do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, com a redação que lhe foi dada pela Lei n.º 11.464/07.

No tocante à pena de multa, fixo-a acima do mínimo legal cominado, qual seja, oitocentos dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Ausentes causas de aumento de pena. Assim, em face da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tal reprimenda é reduzida em dois terços, perfazendo o total final de duzentos e sessenta e seis dias-multa.

Frisa-se que o novo art. 387, § 2º, do CPP, dispõe “in verbis”:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

...

§ 2º. O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade."

Logo, considerando que a pena privativa de liberdade fixada ao réu é de DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO, revela-se imperioso proceder à pertinente detração pelo período em que o réu ficou preso preventivamente. No entanto, conforme infra exposto, dada as peculiaridades dos crimes hediondos, essa detração competirá ao Juízo da execução.

Considerando que r. decisão de fls. 70/74 (auto de prisão em flagrante) que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva é datada de 28.06.2021, sendo que a prisão se deu no dia 27.06.2021, tem-se que o réu encontra-se preso há 07 meses e nove dias, considerando a data da presente decisão, qual seja, 04 de fevereiro de 2022.

Logo, à luz da r. sentença, fato é que só resta para o réu cumprir DOIS ANOS E VINTE E UM DIAS DE RECLUSÃO de pena privativa de liberdade. Tal fato jurídico deverá ser observado pelo Juízo da Execução, oportunamente.

Ademais, encontrando-se o réu encarcerado em virtude da prisão em flagrante, convertida em preventiva, tratando-se de crime grave e subsistindo os motivos que ensejaram sua manutenção cautelar no cárcere, é evidente que o sentenciado deverá aguardar preso o julgamento de eventual recurso. Aliás, assim tem prelecionado o eminente mestre e magistrado Guilherme de Souza Nucci: "Se antes do julgamento de mérito, que considerou o acusado culpado, estava cautelarmente recolhido, com mais lógica assim deve permanecer após a condenação." (in"Código de Processo Penal Comentado", 6ª edição, Editora RT, pág. 930).

No mesmo sentido é o pacífico entendimento da jurisprudência: "seria incongruente que o réu preso provisoriamente em virtude de medida cautelar viesse, ao depois de condenado, ser libertado ex-vi da Lei 5.941/73. Poder-se-ia, então, dizer que ficou preso pelo menos e foi posto em liberdade pelo mais"(RT 504/339).

Assim, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça: "Inaplicável é a outorga do benefício a quem já se encontra preso, em flagrante ou preventivamente, por ocasião da sentença condenatória." (RHC 177 RJ 5ª Cam. do STJ, v.u., rel. M. Assis Toledo, DJU de 30.10.89.).

Ainda no tocante à pena privativa de liberdade, revejo entendimento outrora adotado por esse Juízo acerca da detração penal, senão vejamos.

Determina o art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal que o Juiz, ao proferir sentença condenatória, deverá observar o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, a ser computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Basta analisar a exposição de motivos da Lei n. 12.736, de 30 de novembro de 2012, para que se conclua, com clareza solar, que a pretensão do legislador - em franca homenagem à individualização das penas - foi justamente prever, para o Juízo do conhecimento, mais um critério a ser considerado na fixação do regime de cumprimento da pena, além do disposto no art. 33 c.c. art. 59, ambos do Código Penal, qual seja, o desconto, de imediato, do lapso temporal de cumprimento da pena privativa de liberdade em sede cautelar, o que não se confunde com "progressão de regime", objeto específico do Juízo da Execução, senão vejamos:

"3. Comumente ocorre que, após a sentença condenatória ter sido proferida, tenha o réu que aguardar a decisão do juiz da execução penal, permanecendo nesta espera alguns meses em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus, em razão de não existir previsão expressa no Código de Processo Penal conferindo ao juiz do

processo de conhecimento a possibilidade de, no momento da sentença, realizar o desconto da pena já cumprida. [...] 6. O que se almeja com o presente projeto, é que o abatimento da pena cumprida provisoriamente possa ser aplicada, também, pelo juiz do processo de conhecimento que exarara sentença condenatória conferindo maior celeridade e racionalidade ao sistema de justiça criminal, evitando a permanência da pessoa em regime que já não mais corresponde à sua situação jurídica concreta.”

Isto posto, cumpre trazer à colação trecho de elucidativo acórdão acerca da questão, oriundo da 13ª Câmara de Direito Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, da lavra do eminente Des. Renê Recupero, senão vejamos:

“De outra parte, prevalece, nesta Turma Julgadora, o entendimento de que o § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 12.736, de 30-11-2012, contém duas regras principais: a) cuida somente da determinação, isto é, da fixação do regime inicial, já na sentença condenatória, uma vez que, não se tratando de progressão, inexistente a necessidade da presença do requisito subjetivo (merecimento); b) alcança somente a hipótese em que a fixação do regime prisional se faz, única e exclusivamente, em razão do quantum da pena.” (Habeas Corpus n.º 0190234-85.2013.8.26.0000, da Comarca de Ilha Solteira, “Conheceram em parte da impetração e, na parte conhecida, denegaram a ordem. V.U.”, de conformidade com o voto do Relator; São Paulo, 16 de janeiro de 2014).

Ora, considerando que o delito de tráfico de drogas está sob o regime jurídico dos CRIMES HEDIONDOS, é imperioso reconhecer que o regime inicial de cumprimento da pena NÃO é fixado única e exclusivamente em razão do quantum da pena, pois, em face do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, o regime inicial deve inexoravelmente ser FECHADO.

Tal peculiaridade afasta, por evidente, a aplicabilidade, pelo Juízo do conhecimento, do disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal. Assim, para o condenado pela prática de tráfico de drogas a detração dar-se-á apenas e tão só para fins de “progressão de regime prisional”, matéria essa de competência exclusiva do Juiz da Execução Criminal, regulada pela legislação específica.

Logo, nesse processo de conhecimento, não há que se falar em detração e consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, “in casu” resta fixado o regime inicial FECHADO.

Ainda que assim não fosse, fato é que, dada a gravidade do crime em questão, reputo que, nesse caso (elevadíssima quantidade de drogas e especial periculosidade do agente) não se encontram presentes os pertinentes requisitos necessários para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, “ex vi” do disposto no art. 44, III, do Código Penal.

Assim tem entendido a mais abalizada jurisprudência, senão vejamos: “Incabível a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, não apenas em razão da natureza do crime, dotado de expressiva danosidade social, merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5º, XLIII), aos quais o legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2º, Lei 8.072/90), mas, notadamente, por se verificar que, in casu, face à evidência de não se tratar de pequeno e eventual traficante, tendo em vista a quantidade da droga apreendida, tais medidas não seriam socialmente recomendáveis. Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.” (TJSP Apêl. 0031818-67.2010.8.26.0309; d.j. 17/05/2013).

Ou ainda:

“Não parece razoável que o condenado por tráfico de entorpecentes, seja ele de pequeno, médio ou grande porte, seja beneficiado com essa substituição, porque, em todas as suas modalidades, trata-se de delito de extrema gravidade e causador de

inúmeros males para a sociedade, desde a desestruturação familiar até o incentivo a diversos outros tipos de crimes gravíssimos, que, não raro, têm origem próxima ou remota no comércio ilegal de drogas, sem falar do problema de saúde pública em que já se transformou.” (HC 203.403/SP, Rel. Min.Napoleão Nunes Maia Filho, 5ª T, j. 21/06/2011, DJe 01/07/2011).

Por fim, com bem prelecionou o culto Desembargador Ricardo Tucunduva, “... o tráfico de drogas é delito incompatível com tais benefícios, podendo o legislador, então impor maior rigor na sanção aplicada aos seus infratores, em prol dos interesses da população ordeira e trabalhadora de nosso país...” (TJSP - 6ª Câmara de Direito Criminal, Ap. n.º0000472-64.2011.8.26.0115, j. 02.02.12).

No tocante ao incidente em apenso, tendo por objeto a restituição do veículo a terceiro, tem-se que não merece albergamento a pretensão deduzida pelo Sr. Eduardo Luis F. Sacoman, senão vejamos.

Embora o Sr. Eduardo tenha comprovado a aquisição do carro frente ao proprietário que consta no DUT, qual seja, José Carlos Gomes, a prova dos autos é no sentido de que o Sr. Eduardo é vendedor de carros.

Não há efetiva demonstração da existência de laços familiares ou de amizade que justifique o Sr. Eduardo “emprestar” o carro para a mãe do réu.

Por outro lado, como bem ressaltado pela zelosa Promotora de Justiça, os policiais foram enfáticos no sentido de que já tinham visto o réu na condução do Fiat Punto anteriormente e, ainda, que a mãe do acusado compareceu no local, quando da prisão, falando que o carro era dela.

Ora, é muito comum que vendedores de carro – como o Sr. Eduardo – realizem a venda do automóvel através de financiamento “particular”, ou seja, parcelamento com juros diretamente entre o vendedor e o comprador.

Nesse tipo de operação, a tradição do veículo é realizada imediatamente e, após a quitação do carro, o vendedor faz a transferência da documentação. Daí o réu e sua mãe estar na posse do carro, ao passo que os documentos estavam em poder do vendedor Eduardo.

Ora, se o Sr. Eduardo comprou o carro para si – e não para revender – não há motivo algum para que o carro ficasse ainda em nome do Sr. José Carlos Gomes.

Na verdade, a prova dos autos é apta para lastrear a conclusão judicial de que se trata de “carro de negócio”, adquirido pelo Sr. Eduardo do Sr. José e, então, revendido para a mãe do réu, negócio jurídico esse concretizado pela entrega da posse direta do bem ao novo adquirente.

Não há contrato com cláusula de reserva de domínio. Logo, caberá ao Sr. Eduardo valer-se das vias ordinárias para o recebimento do crédito que possui frente à compradora, mãe do réu.

Isto posto, na medida em que o carro Fiat Punto foi utilizado para a prática de tráfico de drogas, o decreto de seu perdimento, na forma da lei, é imperioso.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e, assim CONDENO o réu CAIO GABRIEL SILVA, RG n.º 57168089, filho de Mara Cristina Alves Silva e José de Souza e Silva, por infração ao art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade no importe de DOIS ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO , bem como DUZENTOS E SESSENTA E SEIS DIAS-MULTA, com valor unitário no mínimo legal. Em face do disposto no art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90, consigna-se que o regime inicial de cumprimento da pena é o FECHADO. O réu não poderá apelar em liberdade,

vez que ainda presentes os requisitos para manutenção da prisão cautelar.

Após o trânsito em julgado, anatem-se as condenações definitivas no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, nos termos do Provimento n.º 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Cartório Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Proceda-se à destruição das drogas apreendidas, caso referida providência ainda não tenha sido determinada, nos termos do art. 50, § 3º, da Lei n.º 11.343/06; com o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das eventuais amostras guardadas para a contraprova, certificando-se nos autos, consoante art. 72 da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista que o art. 91, II, do Código Penal, juntamente com o art. 63, da Lei n.º 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento do veículo Fiat Punto de placas FNF6F22, chassi 9BD11818LE1281537, renavan 00669208272, apreendido nos autos. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis. Expeça-se o necessário.

Como corolário da emissão do decreto supra, condeno o réu ao pagamento de 100 (cem) UFESP's, "ex vi" do disposto no art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei n.º 11.608/2003.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Intime-se o Eduardo Luis F. Sacoman, na pessoa de seu nobre advogado, face a decisão do incidente nessa sentença.

P.R.I.C.

Lençóis Paulista, 21 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA